

共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲がAの殺害を乙に教唆したところ、乙はAの殺害を丙に教唆し、さらに、丙はAの殺害を丁に教唆し、丁がAを殺害した。甲には、殺人罪の教唆犯が成立する。
2. 乙は、路上で、Aの頭部を殴って転倒させ、Aに脳挫傷の傷害を負わせたが、その直後に駆けつけた甲は、Aが乙の暴行によって倒れて苦しんでいることを知り、Aの抵抗が困難になっている状態を利用してAに暴行を加えようと考え、乙と意思を通じ、代わる代わるAの腹部を蹴り、腹部に打撲傷の傷害を負わせた。甲には、脳挫傷の傷害についても乙との傷害罪の共同正犯が成立する。
3. 甲は、乙からAの殺害計画を打ち明けられ毒薬の入手を依頼されたことから、毒薬を購入して乙に渡したが、乙は、毒薬での殺害計画を変更し、Aを包丁で刺して殺害した。甲には、殺人予備罪の共同正犯が成立する。
4. 甲と乙は、A方に強盗に入ることを計画し、それぞれ包丁を持ってA方に侵入し、Aを包丁で脅した上、室内を物色していたところ、家人B、Cに犯行を目撃され、甲はBに捕まったが、乙は逮捕を免れるためCの腕を包丁で切り付けて傷害を負わせた。甲には、住居侵入罪のほか強盗致傷罪の共同正犯が成立する。
5. 暴力団組員乙は、対立する暴力団組長Aを殺害することを決意し、誰にも犯行の決意を打ち明けることなく、小刀を持ってA方に向かったところ、乙の舎弟である甲は、乙の決意を察し、仮に乙がAから反撃されそうになった場合は、自分がAを殺害しようと考え、乙に何も告げることなく、拳銃を持ってA方付近に先回りして隠れていたが、乙は、玄関先に出てきたAを小刀で一突きして殺害した。甲には、乙の殺人罪の従犯が成立する。

No162

H28-19

## 共 犯

正 解

2、5（順不同）

正答率

72%

## 1 正しい

大判大11.3.1。61条1項は、正犯の教唆の処罰を規定し、同条2項は教唆者の教唆（間接教唆）の処罰を規定しているが、刑法は、教唆者を教唆した者を更に教唆した場合（再間接教唆）について明文規定を置いていない。そこで、再間接教唆者が処罰されるかが問題となる。判例は、文理解釈から、教唆者を教唆した者もまた一種の教唆者であり、それを更に教唆した再間接教唆も、61条2項の「教唆した者」に当たるとしてその処罰を肯定している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、教唆行為は正犯者に犯罪の実行を決意させる点にその可罰性があり、再間接教唆といえども、その行為と正犯の犯罪行為との間に相当な因果関係がある以上は、処罰に値する点を挙げている。本記述では、A殺害について、甲が乙に教唆し、乙が丙に教唆し、更に丙が丁に教唆し、丁がAを殺害しており、甲が再間接教唆者に当たる。よって、甲には、殺人罪の教唆犯が成立する。

## 2 誤っている

最決平24.11.6（百選I81事件）。判例は、先行者A、Bが共謀してC、Dに暴行を加えて傷害を負わせた後に、Aらに共謀加担した被告人が、金属製はしごや角材を用いて、Dの背中や足、Cの頭、肩、背中や足を殴打し、Dの頭を蹴るなど更に強度の暴行を加え、少なくとも、共謀加担後に暴行を加えた上記部位についてはC、Dの傷害を相当程度重篤化させたという事案において、「被告人は、共謀加担前にAらが既に生じさせていた傷害結果については、被告人の共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないから、傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく、共謀加担後の傷害を引き起こすに足る暴行によってCらの傷害の発生に寄与したことについてのみ、傷害罪の共同正犯としての責任を負う」としている。本記述では、甲は、乙と意思を通じて、Aに対する傷害行為を行っているが、共謀加担後のAの腹部打撲傷についての傷害結果についての責任を負うにとどまり、共謀加担前に乙が単独でAに加えた脳挫傷の傷害については、甲の共謀及びそれに基づく行為との間に因果関係が認められず、共同正犯としての責任を負わない。よって、甲には、脳挫傷の傷害については乙との傷害罪の共同正犯は成立しない。

## 3 正しい

最決昭37.11.8（百選I80事件）。本記述では、①予備罪の共同正犯の成立を認めることができるか（予備の共犯の成否）、②他人予備では自ら殺人を犯す「目的」を持っていないので、予備罪の正犯たり得ず、不可罰である予備の幫助にとどまるのではないか（他人予備の成否）が問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、殺人予備罪の共同正犯が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、①60条の「実行」には修正された構成要件に該当する行為も含むから、基本的構成要件に該当する事実の実現を目的とする2人以上の者が共同してその予備を実行したときは、予備の共同正犯が成立するとした上で、②他人の犯罪実現目的で予備行為に加功した者も、共同実行の意思と共同実行の事実とが存在する以上、65条1項の非身分者の加功による共同正犯として、自ら基本犯を犯す目的がないとしても予備罪の共同正犯の成立が認められるということを挙げている。よって、甲には殺人予備罪の共同正犯が成立する。

## 4 正しい

最判昭26.3.27（百選Ⅰ〔第7版〕79事件）。判例は、強盗の共犯の1人が、強盗に着手した後、家人に騒がれて逃走し追跡されているうち、巡査に発見され追い付かれて逮捕されようとした際、逮捕を免れるため同巡査に切りつけ死に至らしめたという事案において、被告人「の傷害致死行為は強盗の機会において為されたものといわなければならないのであつて、強盗について共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負うべきものである」として、共犯者全員について強盗致死罪の共同正犯が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、基本となる犯罪について意思の連絡があれば、それと刑法的因果関係のある範囲内の結果が共同正犯者に因果的に帰責されるのは当然であるということ并举げている。本記述では、甲乙間には基本犯たる強盗罪の実行につき意思の連絡があり、乙が逮捕を免れるためにCの腕に加えた傷害結果は、それと刑法的因果関係のある範囲内の結果に当たる。よって、甲には、住居侵入罪のほか強盗致傷罪の共同正犯が成立する。

## 5 誤っている

幫助犯（従犯）とは、「正犯を幫助」した者をいい、幫助とは、正犯者でない者が正犯の実行を容易にさせることをいう（最判昭24.10.1参照）。幫助の方法は物理的方法であると精神的方法であるとは問わないが、幫助犯の成立のためには、正犯の実行を促進する幫助行為により正犯行為を促進して、その正犯行為の危険性の現実化として構成要件の結果が発生したこと（因果関係）が必要である。本記述では、甲は正犯である乙に何も告げておらず、乙が甲の助力の意図を知っていたという事情もないので、甲の行為には精神的に乙の正犯行為を促進したという関係はなく、また現実には甲は犯行現場で隠れていたにすぎず、甲の行為には物理的に乙の正犯行為を促進したという関係もない。よって、甲の行為には物理的にも精神的にも乙の実行を容易にさせた関係はなく、甲は「正犯を幫助」した者に当たらず、甲には乙の殺人罪の従犯は成立しない。なお、裁判例も、正犯の強盗殺人を幫助するため殺害現場として予定されていた地下室に目張り等をして準備をしていたところ、それを知らない正犯が殺害現場を変更して、強盗殺人を実行した事案において、目張り等の行為自体、正犯を精神的に力付け、正犯の犯罪の意図を維持ないし強化することに役立ったなかったことを理由に、従犯の成立を否定している（東京高判平2.2.21、百選Ⅰ88事件）。